

1527526-28.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527526-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527526-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DUARTE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

FERNANDO DUARTE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, ambos c/c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, em ocasião de calamidade pública, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 10h, na travessa Música do Dilema, nº 15, Jardim Iae, nesta cidade e comarca de São Paulo, tinha em depósito e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 1.753 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 1170,5g, 386 porções de "maconha" (THC), com peso líquido de 881,5g, 29 frascos de Cloreto de Metileno, popularmente conhecido como "Lança Perfume", com peso líquido de 870 mililitros, substância nominada na Lista D2 da Portaria SVS/MS nº 344/98 (lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos), e 238 porções de cocaína petrificada na forma de "crack", com peso líquido de 37,2g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima transcritas, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 1 (um) cartucho íntegro de munição de uso permitido calibre 32, e 5 (cinco) cartuchos íntegros de munição de

uso permitido calibre 9 mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 68/74).

A denúncia foi recebida (fls. 113/119), o réu foi citado (fl. 175) e apresentou defesa prévia (fls. 199/202).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fl. 209), foram ouvidas três testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

A defesa, a seu turno, pugnou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes e aplicação do privilégio no patamar máximo. Ainda, o afastamento da agravante referente à calamidade pública.

Juntados laudos, científicas as partes, reiteraram as manifestações anteriores.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 13/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo laudo de constatação (fls. 57/60), pelo laudo pericial de exame de cartuchos de munição (fls. 184/187), pelo laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 57/60), laudo referente às munições (fls. 184/187) bem como pela prova oral.

No mérito, a autoria está demonstrada.

Ana Cristina Duarte de Oliveira, testemunha, afirmou em Juízo que estava em casa e deparou-se com vários policiais dizendo que estavam com a foto de seu marido, que estavam num flagrante oriundo de investigação referente a posse de drogas. Entraram na casa e não apresentaram mandado de busca e apreensão. Foram até o último andar e desceram com uns sacos. Foi a depoente quem indicou o local onde dormia. Não mostraram o que havia nos sacos. Depois disseram que eram drogas. Encontraram um cofre que continha R\$4400,00 e munições. Negou a existência das drogas, confirmou os cartuchos e o valor, que era da adega. Levaram o notebook de sua filha. Negou as declarações contidas na fl. 11. Não sabe dizer qual o motivo pelo qual constaram tais declarações na fase policial. Trabalhava na adega. Negou a existência das drogas,. Confirmou a existência das munições. Confirmou a posse do dinheiro.

Rafael Moura da Silva, policial civil, afirmou em Juízo que foram cumprir mandado de busca e apreensão. A mulher franqueou a entrada e disse que o ex-marido morava ali e que se houvesse drogas, ela não tinha ciência. Ela apontou o quarto habitado por ele onde foi encontrada a mochila, com relevante quantidade de drogas, cofre, dinheiro, uma caixa com munições e questionada, ela fez algumas ligações e 10 minutos depois, o acusado retornou. Quanto ao dinheiro, ele disse que era da adega. Quanto ao mandado e busca relatou que havia inquérito investigando tráfico.

Luiz Carlos de Souza Dias, policial civil, afirmou em Juízo que foram cumprir o mandado de busca e no local, foram atendidos pela esposa do acusado. Apresentaram o mandado, a sra. Ana Cristina autorizou a entrada. Ela relatou que estavam em separação de corpos, embora morassem juntos. Ela apontou o quarto como sendo

ocupado pelo acusado e encontraram uma mochila contendo drogas e munições. Ainda, foi encontrado dinheiro. Tudo se originou de uma prisão em flagrante feita um tempo atrás, referente a uma organização salvo engando. Fizeram diligências, foram ao local, tiraram fotos indicando as casas onde tinham drogas guardadas. O valor apreendido foi cerca de três mil e novecentos reais. Ele disse que o dinheiro era da venda da adega. Ele indicou a adega que teria sido vendida. Afirmou que a esposa sabia da existência do cofre onde estava o dinheiro e ela disse que era da adega. Nesse dia tinham informações referentes a 4 casas, dentre elas, a do acusado. Forma levados pelo réu até a adega, mas lá nada de ilícito foi encontrado. Não foi apurado que houvesse relação entre os endereços nos quais cumpridos os mandados. Não se recordou se as notas existentes no cofre eram notas altas ou não. As drogas estavam fracionadas, pronta para a venda, todas no interior da mochila encontrada no quarto onde o réu dormia.

Interrogado, o réu Fernando Duarte de Oliveira alegou que passou a noite trabalhando. Pela manhã, foi para a casa e soube que a polícia estava lá. Chegando de volta à adega, encontrou dois policiais com a sua esposa, dizendo terem encontrado drogas em sua casa. Acompanhou-os até o automóvel e lá estavam os sacos e a mochila. Disseram terem encontrado drogas na sua casa. Os vizinhos que avisaram eles foram direto na casa do acusado, não foram em outras casas. Tem mais outras casas correspondentes ao número 15. A respeito da versão da esposa, nada tem a acrescentar. Na ocasião, estava um rapaz e uma moça dizendo que a policiais tinha invadido a casa deles. Nunca teve problema com polícia. Nunca viu esses policiais antes dos fatos. Afirmar que o dinheiro era furto da adega e que fazia compras uma vez por semana.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Ainda que a companheira do acusado em juízo tenha negado completamente as declarações de fl. 11, relatando que houve invasão e que as drogas não lhe foram mostradas, porém, confirmando que desceram com os sacos sem, contudo, relatar que bens teriam sido levados de sua residência, uma vez que não negou que os sacos e a mochila tenham sido levados. Apenas viu o notebook da filha, porém, não percebeu que outros objetos tivessem sido levados. Necessário apontar que não é válido o compromisso à medida em que se declarou, quando compareceu a juízo, esposa do acusado.

Em contrapartida, o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) relata a apreensão das drogas, inclusive do notebook mencionado pela informante Ana, assim como 6 aparelhos celulares, o valor referido (R\$3.850,00) e as munições.

Na sequência, foram ouvidos os policiais civis que relataram o cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 50/51). Descreveram a notícia a respeito de locais onde poderiam ser encontradas drogas, realizando-se investigação da qual resultou a concessão da ordem de busca. Embora a companheira do acusado, Ana, tenha declarado em juízo que não houve autorização de ingresso, tampouco apresentação do mandado, contrariamente ao quanto relatado na fase policial, verifica-se à fl. 08 a menção ao mandado, assim como sua cópia às fls. 50/51. E ainda que haja alguma referência a existência de várias moradas identificadas com o número 15, não é o que se constata nos autos pelas fotos (fls. 52 e 55) apresentadas pela defesa.

Importante, ainda, mencionar que o ato foi acompanhado por outras pessoas além da companheira do acusado (fls. 38/39) sendo que nenhuma delas foi chamada para negar o fato documentado. Assim, não existem provas das irregularidades declaradas pelo acusado e por sua companheira, Ana.

Além disso, nenhuma prova foi apresentada de que os policiais tivessem interesse

concreto em prejudicar ao acusado.

Ainda, com relação ao exame grafotécnico, haja vista a apreensão uma caderneta e o computador foi encaminhados para a perícia (fls. 90 e 91/95) dos quais não forma extraídas informações capazes de relacionar o acusado à droga apreendida (fls. 341/347). Contudo, não é suficiente para afastar. Isto porque o resultado positivo corroboraria os elementos já existentes contra o réu. Existem elementos fortes o bastante consistente no cumprimento do mandado de busca do qual resultou a efetiva apreensão tanto das drogas, quanto do valor e das munições apreendidas.

Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou provado que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos.

A quantidade, variedade, existência de anotações e alto valor apreendido demonstram a destinação de tráfico.

Com relação ao crime de descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de

Ocorrência dos fatos (fls. 13/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo laudo pericial de exame (fls. 184/187), bem como pela prova oral.

Com efeito, como acima referido, as munições foram apreendidas na residência do réu no contexto já demonstrado. Neste ponto importante observar que a ocorrência de crime concomitante fortalece a tipicidade da conduta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido.

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

Quanto ao crime de tráfico:

Em primeira fase, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não está comprovado que tenha se aproveitado da calamidade pública para a prática dos fatos, ficando afastada. Não há agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pois diante da quantidade de drogas, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sua conduta está em completo descompasso com a aplicação do redutor porquanto demonstra relação de confiança com as pessoas que autorizam a venda e fornecem drogas, observando-se a grande quantidade que o acusado tinha em seu poder.

Para o crime artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Seguindo os mesmos parâmetros, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes, tampouco causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 69, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena fixada, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena para o crime de tráfico e aberto para aquele punido

com detenção.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu FERNANDO DUARTE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões informadas nos autos para sua exacerbação, ainda como incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O réu esteve preso durante todo o transcorrer da instrução criminal e foi condenado pela prática de crime grave, cuja prática sobressalta a ordem pública e recomenda a manutenção da segregação também para fins de assegurar a aplicação da lei penal, além de haver sido condenado por fato semelhante. Assim, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se à prisão em que se encontra.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Oficie-se ao Comando do Exército encaminhando-se a munição apreendida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados .P.R.I.C.

São Paulo 24 de maio de 2022.